

0000842-83.2021.8.26.0441

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... que a criminalização se justificaria no combate ao tráfico. Embora com alguma lógica cartesiana, a afirmação esbarra no princípio de que, em direito penal, as condutas devem ser individualizadas, não se punindo aquele que não causou, direta ou indiretamente, o perigo ou o dano. Por tal razão, apenas o traficante deve ser punido pelo mal que gera: a distribuição das drogas sem nenhuma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

0000842-83.2021.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000842-83.2021.8.26.0441

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIZANDRA PEREIRA LUSTOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

FELIPE PEREIRA LUSTOSA e ELIZANDRA PEREIRA LUSTOSA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, sendo ela nas sanções dos artigos 28, e ele no incurso do art. 33, §3º, ambos da Lei 11.343/2006, segundo a denúncia, no dia 04 de janeiro de 2020, por volta das 19:40h, na Avenida Governador Mário Covas Júnior, nº 3.735, centro, nesta cidade e comarca, Felipe ofereceu droga, sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento, consistentes em seis porções de maconha, com peso bruto de 22 gramas e Elisandra trazia consigo, para consumo pessoal e sem autorização, seis porções de Cannabis sativa L, com peso bruto de 22 gramas.

Felipe foi devidamente citado às fls. 83 e a citação de Elisandra ocorreu em audiência de instrução, oportunidade em que a denúncia foi recebida. 172.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e os réus foram interrogados, oportunidade em que foi encerrada instrução.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público, requereu a condenação nos termos da denúncia, manifestando-se sobre a dosimetria da pena e aplicação das penas.

A Defesa, por sua vez, alegou a ausência de materialidade e autoria em relação à Felipe, no que tange à Elisandra, aplicação do princípio da insignificância, ante a pequena quantidade e ausência de dano, pugnou pela absolvição dos réus.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A priori, determino o apensamento dos autos 0000842-83.2021.8.26.0441 ao processo nº 1500014-47.2020.8.26.0441 e passo a julgá-los de forma conjunta.

Eis a síntese da prova oral produzida.

A testemunha Igor Pereira disse que não se recorda dos rostos e referente à ocorrência pela Avenida Mario Covas quando avistaram o veículo, o motorista demonstrou nervosismo, em vistoria, com a Elisandra, localizam substâncias análogas a maconha e foram conduzidos ao DP. O Felipe disse que teria comprado a maconha para Elisandra.

A testemunha Sheldon Gonçalves Nunes, policial militar, disse que no dia dos fatos, estava em patrulhamento, avistaram um carro no contrafluxo, um rapaz dirigindo, irmão da Elisandra, abordaram, no veículo e nos indivíduos, nada foi encontrado. Com a Elisandra, localizaram, maconha, para uso. O irmão disse que teria deixado com ela. Não estavam consumindo.

Devidamente interrogada, Elisandra Pereira Lustosa, confessa os fatos da denúncia, disse que é usuária de maconha, tinha ido à praia e o irmão/pai não sabiam deste entorpecente. Não foi Felipe que comprou a droga, trouxe de Indaiatuba.

Interrogado, Felipe Pereira Lustosa, nega os fatos da denúncia, disse que a irmã estava com drogas. No dia disse que a droga não era sua e sim do irmão. É usuário de drogas e desconhecia dos entorpecentes.

Da análise detida dos autos, verifica-se que, em relação à conduta de Felipe, não foram produzidas, em Juízo, provas suficientes para embasar a condenação.

Nesse ponto, observo que, em juízo, os policiais ouvidos relataram que Felipe teria confirmado a compra da maconha informalmente. Contudo, não viram qualquer ação por parte do réu, seja de compra do entorpecente, seja de entrega da droga para a irmã.

A irmã Elisandra, por sua vez, disse que a droga não lhe foi entregue pelo Felipe e que trouxera o entorpecente de Indaiatuba.

Felipe, em juízo, negou que tivesse comprado as drogas e dado à irmã.

O prolação de decreto condenatório pressupõe a existência de prova inequívoca da materialidade e da autora do delito que motivou a instauração do processo penal. Prova, no direito brasileiro, é aquela produzida em contraditório judicial, razão pela qual, a teor do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que se aplica analogamente ao caso em tela: "Importa registrar que a prova produzida

extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal. Assentir com entendimento contrário implicaria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significaria inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Assim, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos" (AgRg no REsp 1740921/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Quinta Turma, j. 06/11/2018).

O art. 5º, LIV, da Constituição Federal assegura a todo cidadão que ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Mais adiante, o inciso LVII estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Da mesma forma dispõe o art. 8º, 2, do Pacto de San José da Costa Rica, incorporado pelo Decreto 678/92, que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

Não resta dúvida de que o exercício da jurisdição penal deve observar o devido processo legal substantivo. Cabe ao Poder Judiciário, após a instrução do feito, analisar se as provas produzidas são bastantes para fundamentar a privação da liberdade do réu. Tal atividade probante, cujo resultado poderá infirmar a presunção de inocência do sujeito, deverá ser feita perante um Poder imparcial e equidistante, constitucionalmente destinado a preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Persistindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos mesmo após a instrução, não se atinge o padrão ("standard") probatório exigido para ensejar uma condenação.

"Somente havendo prova robusta, forte, altamente confiável, de indiscutível qualidade epistêmica, que se traduza em um alto grau de verossimilhança, de probabilidade (ou certeza, para quem admite essa categoria na perspectiva processual), que supere toda e qualquer dúvida fundada sobre questões relevantes do caso penal, é que autoriza uma sentença penal condenatória, pois é apta a superar a barreira do "acima da dúvida razoável" e consegue dar conta do nível de exigência da garantia da presunção de inocência" (Junior, Aury Celso Lima L. DIREITO PROCESSUAL PENAL. Editora Saraiva, 2021 - e-book).

Nesse caso, aplica-se a máxima segundo a qual a dúvida favorece o réu, em decorrência da presunção de inocência. A propósito, o seguinte precedente do Tribunal de Justiça:

1-) Apelação criminal. Furto tentado. Sentença absolutória. Inconformismo da Acusação. 2-) Materialidade duvidosa. As provas colhidas nos autos deixam dúvida acerca da dinâmica do ocorrido e do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado, sendo que a dúvida deve favorecer o réu. Para proferir-se uma condenação criminal é preciso que haja prova escorreita e segura da existência do fato delituoso e de sua autoria para que a presunção de inocência que milita em favor do acusado seja elidida. E no caso em estudo, isso não ocorreu. 3-) Não provimento do recurso do Ministério Público. (TJSP; Apelação Criminal 1518063-96.2020.8.26.0228; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020).

Assim, em relação a Felipe, é caso de absolvição por falta de provas da ocorrência do delito.

Em relação ao crime imputado a Elisandra, a conduta ora analisada não merece repressão estatal pela via do Direito Penal. É princípio jurídico-penal basilar aquele segundo o qual a tutela repressiva do Estado, no âmbito criminal, deve se ater à proteção de bens jurídicos relevantes, reprimindo apenas condutas que tenham aptidão para causar-lhes lesão. Trata-se do princípio da lesividade.

Não se vislumbra, no caso dos autos, qualquer lesão jurídica relevante a qualquer bem jurídico, nem mesmo à saúde pública, dada a inexpressividade da conduta. A ré tinha consigo pequena quantidade de maconha (13,8 gramas - massa líquida - fls. 176/178 dos autos nº 1500014-47.2020), destinada ao consumo próprio.

É sabido que o Direito Penal não pune a autolesão ou o risco de autolesão, de modo que os eventuais males que o consumo da droga possa fazer à acusado não autorizam a aplicação da lei penal.

Em sentença proferida em caso análogo, a eminente magistrada deste Eg. TJSP, Ana Rita de Figueiredo Nery, pontuou:

"Em uma sociedade plural, como preconizado no Preâmbulo da Constituição Federal, pessoas têm convicções diferentes, encontrando bem-estar de maneiras distintas e arcando com as consequências pessoais de tal ou qual decisão. Nesta sociedade, o Estado só age para evitar que a conduta de uma pessoa interfira na vida de outra, garantindo o exercício harmônico das liberdades humanas. Adotada esta premissa, a proibição do uso de drogas é inconstitucional. O porte de drogas para uso próprio diz respeito apenas ao usuário. Não é possível dizer a priori que este, ao consumir drogas, vai cometer qualquer crime. De todo modo, se isso ocorrer, haverá a punição pelo crime cometido. Tampouco é válida a afirmação de que existirá punição pelo crime cometido com vistas à drogadição. Tomado em si mesmo, o uso de drogas nada gera além da alteração de consciência, obtida também por meio de substâncias lícitas, como o álcool e o tabaco. Não há coerência na permissão de umas e proibição de outras. Tem-se, daí, a intenção estatal de impor um padrão de conduta, decorrente de uma suposta maioria, tratando como crime (com todas as consequências seríssimas decorrentes, incluindo a inclusão de maus antecedentes) aquilo que, de há muito se diz, deveria ser tratado como questão de saúde pública. Inválido, juridicamente, o argumento corrente de que a criminalização se justificaria no combate ao tráfico. Embora com alguma lógica cartesiana, a afirmação esbarra no princípio de que, em direito penal, as condutas devem ser individualizadas, não se punindo aquele que não causou, direta ou indiretamente, o perigo ou o dano. Por tal razão, apenas o traficante deve ser punido pelo mal que gera: a distribuição das drogas sem nenhuma preocupação com as consequências que sua disseminação causará. Por tudo isso, entende-se que a criminalização do uso de drogas, ou do porte para o uso delas, configura restrição indevida da liberdade, com violação ao que dispõe o artigo 3º, IV, da Constituição Federal, dispositivo que veda todas as formas de discriminação" (autos nº 0003291-24.2016.8.26.0268).

Em outras palavras, o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 não se harmoniza com o direito fundamental à intimidade e à vida privada, previsto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, porque visa à punição de uma conduta cuja repercussão se restringe ao âmbito interno do indivíduo.

Também não há compatibilidade entre a criminalização da posse de drogas para uso pessoal e alguns dos princípios fundamentais do Direito Penal, a saber, os da lesividade, da fragmentariedade, da alteridade, da exclusiva proteção a bem jurídicos e da intervenção mínima.

A esse respeito, o precedente deste Eg. TJSP:

"(...) 2 - O artigo 28 da Lei n. 11. 343/2006 é inconstitucional. A criminalização primária do porte de entorpecentes para uso próprio é de indisfarçável insustentabilidade jurídico-penal, porque não há tipificação de conduta hábil a produzir lesão que invada os limites da alteridade, afronta os princípios da igualdade, da inviolabilidade, da intimidade e da vida privada e do respeito à diferença, corolário do princípio da dignidade, albergados pela Constituição Federal e por tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil. (...)" (Ap. Criminal 0023470-50.2006.8.26.0196, Rel. José Henrique Rodrigues Torres, 6ª Câ. de Direito Criminal, j. em 15-6-2009, DJe 18-8-2009).

Quanto ao princípio da alteridade, segundo o qual não pode o direito penal sancionar a lesão que não transcenda o âmbito interno do próprio agente, convém transcrever a importante lição doutrinária de Paulo Queiroz:

"Somente podem ser erigidos à categoria de criminosos fatos lesivos de bem jurídico alheio, e não atos que representem uma "má disposição" de direito próprio. Nesse sentido, aliás, é o "núcleo" do Direito Penal brasileiro, visto que não se pune o suicídio tentado, a automutilação, o dano à coisa própria etc., mesmo porque semelhante intervenção seria de todo inútil, isto é, desprovida de capacidade motivadora. E é também por isso que soam claramente inconstitucionais disposições como a do art. 16 da Lei n. 6.368/76 (porte ilegal de entorpecentes) [atualmente previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006] ou a contravenção de mendicância (LCP, art. 60)" (Direito penal e liberdade, Boletim IBCCrim, p. 5).

Já Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini explicam que "embora o princípio da alteridade não seja nominalmente citado no texto constitucional, assim como o da exclusiva proteção a bens jurídicos, ele deflui diretamente dos valores agasalhados pela Constituição e pelo Estado Democrático de Direito. O art. 5º, X da Carta Magna considera invioláveis a intimidade e a vida privada. Tal dispositivo protege as escolhas dos indivíduos no âmbito privado, desde que não ofensivas a terceiros. Decorre dessa proteção, portanto, que determinado fato, para que possa ser definido como crime, há de lesionar bens jurídicos alheios, de modo que condutas, por lesivas que sejam, mas que se restrinjam ao âmbito privado agente, não podem ser objeto da tutela penal" (Gustavo Octaviano Junqueira e Maria Patrícia Vanzolini Figueiredo. Manual de Direito Penal (7th edição). Editora Saraiva, 2021).

Vale mencionar, ainda, que pende de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário 635.659, versando sobre caso que envolvia a condenação do recorrente pelo consumo de 3 gramas de maconha, em que se discute a (in)constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas.

Já votaram, no referido Recurso Extraordinário, três Ministros da Corte, todos eles em favor da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo.

É digno de reprodução o importante trecho do voto proferido pelo Eminentíssimo Ministro Luis Roberto Barroso, transcrito por Junqueira e Vanzolini na obra acima referenciada:

"O denominado princípio da lesividade exige que a conduta tipificada como crime constitua ofensa a bem jurídico alheio. De modo que se a conduta em questão não extrapola o âmbito individual, o Estado não pode atuar pela criminalização. O principal bem jurídico lesado pelo consumo de maconha é a própria saúde individual do usuário, e não um bem jurídico alheio. Aplicando a mesma lógica, o Estado não pune a tentativa de suicídio ou a autolesão. Há quem invoque a saúde pública como bem jurídico violado. Em primeiro lugar, tratar-se-ia de uma lesão vaga, remota, provavelmente em menor escala do que, por exemplo, o álcool ou o tabaco. Em segundo lugar porque, como se procurou demonstrar, a criminalização termina por afastar o usuário do sistema de saúde, pelo risco e pelo estigma. De modo que pessoas que

poderiam obter tratamento e se curar, acabam não tendo acesso a ele. (...) A criminalização de condutas relacionadas ao consumo promove a exclusão e a marginalização dos usuários, dificultando o acesso a tratamentos. Como assinalou o antropólogo Rubem César Fernandes, diretor do Viva Rio: 'O fato de o consumo de drogas ser criminalizado aproxima a população jovem do mundo do crime'. Portanto, ao contrário do que muitos creem, a criminalização não protege, mas antes compromete a saúde pública”.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o acusado FELIPE PEREIRA LUSTOSA da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia.

Ainda, reconheço, de forma incidental, a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, para, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão punitiva formulada em face de ELIZANDRA PEREIRA LUSTOSA.

Proceda-se à incineração da droga apreendida.

Certificado o trânsito em julgado, façam-se as comunicações de praxe e expeça-se certidão de honorários ao advogado, caso tenha sido ele nomeado pelo Convênio OAB-DPE, em 100% do valor da tabela vigente.

Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade de justiça.

Publicada em audiência.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Peruíbe, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA